

0001864-33.2022.8.26.0348

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... ativamente para a realização do tráfico de drogas, não se trata de um mero colaborador. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Jose Eduardo Vecha, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar à pena. Na primeira fase da aplicação da pena, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

0001864-33.2022.8.26.0348

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2119887/2019 - DEL.POL.MAUA, 4896113 - DEL.POL.MAUA, 221/19/116 - DEL.POL.MAUA, 221/2019 - DEL. POL. MAUA, 2119887 - DEL.POL.MAUA, 221/19/116 - DEL.POL.MAUA, 2119887 - DEL.POL.MAUA, 221/19/116 - DEL.POL.MAUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE EDUARDO VECHA

Data da Audiência:

29/11/2022

Réu Preso

Em 29 de novembro de 2022 às 14h30, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réu privado de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o

Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra. Fabíola Castilho Soffner. Presente o réu José Eduardo Vecha. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presente a testemunha comum Cláudio de Lima Silva. Ausente a testemunha comum Anderson Barbosa Muro. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, foi inquirida a testemunha Cláudio, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Pelas partes foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Anderson, o que foi homologado pelo MM, Juiz. A seguir, pela Defesa foi requerido conversa com o acusado antes do interrogatório, sendo possibilitada a reunião reservada, obedecendo todas as prerrogativas estabelecidas em lei. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. JOÃO IAGO ARANTES, (julgado e condenado no processo nº 1500864-32.2019.8.26.0540 - fls. 261/266), JOSÉ EDUARDO VECHA, qualificado às fls. 23 e 32, e WERLEY GONÇALVES (julgado e condenado no processo nº 1500864-32.2019.8.26.0540 - fls. 261/266), foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 29, do Código Penal, porque, no dia 24 de abril de 2019, por volta das 04h:30min, na Travessa Igatu, nº 1, Vila Magini, nesta cidade e comarca de Mauá, previamente ajustados e com unidade de desígnios, vendiam, traziam consigo e guardavam, para entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 42 invólucros de cocaína, com peso líquido de 16,7g, 42 invólucros de cocaína com peso líquido de 6,7g e 16 invólucros de maconha, com peso líquido de 19g, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo de constatação de fls. 18/21 e laudo químicotoxicológico de fls. 106/109 (fls. 117/118). Foi concedido aos acusados os benefícios da liberdade provisória, mediante aplicação das medidas cautelares (fls. 76/78). A denúncia foi oferecida (fls. 119). O réu José foi notificado por edital (fls. 225 e 280) e apresentou defesa preliminar (fls. 273). Os autos nº 1500864-32.2019.8.26.0540 foram desmembrados em relação ao réu José, dando origem aos presentes autos (fls. 261/266). A denúncia foi recebida (fls. 275). O processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos com base no artigo 366 do Código de Processo Penal, sendo revogada a liberdade provisória e decretada a prisão preventiva do réu (fls. 284/286). O réu foi preso (fls. 297/299) e foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 306/310). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foi inquirida a testemunha Claudio de Lima Silva (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Jose Eduardo Vecha (gravação audiovisual). Nesta audiência, as partes desistiram da oitiva da testemunha Anderson Barbosa Muro (termo de audiência). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Anderson Barbosa Muro (fls. 5) e Claudio de Lima Silva (fls. 3) e os réus Joao Iago Arantes (fls. 7), Werley Goncalves Barbosa (fls. 8) e Jose Eduardo Vecha (fls. 9). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial semiaberto para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu José, em debates, requereu a improcedência da ação ou a desclassificação para os crimes dos artigos 28 ou 37 da

Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o regime aberto, a substituição por penas restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 4). Auto de exibição e apreensão (fls. 14/15). Laudo de constatação provisória (fls. 18/21). Fotos das drogas (fls. 22). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 106/109). Laudo de exame no objeto (fls. 142/144). Laudo de exame de corpo de delito (fls. 302/303). Folha de antecedentes (fls. 57 e 325/326) e certidão (fls. 58). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. Friso que o processo está sendo julgado somente com relação ao réu José, pois, como já observado, os réus João e Werley foram julgados e condenados (fls. 261/266). A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 4), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo de constatação provisória (fls. 18/21), fotos das drogas (fls. 22), exame químico toxicológico definitivo (fls. 106/109), laudo de exame no objeto (fls. 142/144), laudo de exame de corpo de delito (fls. 202/203) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. A testemunha Claudio de Lima Silva, sob o crivo do contraditório, disse que: a) me recordo vagamente da ocorrência; b) no dia fomos fazer operação contra o tráfico de entorpecentes; c) o local era conhecido como ponto de drogas; d) fizemos uma campana e vimos três pessoas, duas nas pontas de uma viela e um no meio; e) nos das pontas nada foram encontrados e no do meio havia uma pochete com maconha, cocaína e crack; f) os das pontas conversavam com as pessoas que os procuravam pediam para levantar as camisetas e apontavam para o meio; g) não me lembro quantos usuários passaram por ele; h) o policial Anderson tem as mesmas informações que eu; i) não lembro as quantidades das drogas, haviam as três drogas e dinheiro, mas a quantidade eu não vou conseguir lembrar (gravação audiovisual e fls. 6). Por fim, o réu Jose Eduardo Vecha, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) eu estava lá somente para comprar drogas; b) conheço o João Iago como traficante, eu somente fui comprar a minha droga; c) o Werley Gonçalves Barbosa foi o que me pediu para levantar a camisa para eu ir comprar a minha droga; d) não sei porque o policial disse que eu pedi para as pessoas levantarem a camisa, eu não conheço ele, eu somente estava na fila esperando para ser atendido, para comprar drogas; e) eu tinha R\$ 5,00 (gravação audiovisual e fls. 9). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 4), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo de constatação provisória (fls. 18/21), fotos das drogas (fls. 22), exame químico toxicológico definitivo (fls. 106/109), laudo de exame no objeto (fls. 142/144), laudo de exame de corpo de delito (fls. 202/203), como também pelos depoimentos das testemunhas Claudio de Lima Silva (gravação audiovisual e fls. 6) e Anderson Barbosa Muro (fls. 5), este que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, foi comprovado que as testemunhas são policiais civis e foram até o local dos fatos, que já era conhecido por eles como ponto de venda de entorpecentes, onde fizeram uma campana e visualizaram os réus Werley e José cada um deles em uma das pontas de uma viela e o réu João no centro dela. Os réus Werley e José pediam para que as pessoas que os procuravam levantassem as camisas e apontavam para o réu João. Então, as testemunhas policiais fizeram a abordagem deles, com os réus Werley e José nada foi encontrado, mas o réu João trazia consigo um estojo, que continha 42 porções de cocaína, pesando 16,7g, 42 porções de cocaína pesando 6,7g e 16 porções de maconha, pesando 19g, além da quantia de R\$ 20,00. A autodefesa do réu restou isolada nos autos, não sendo o caso da desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, em decorrência da "natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente" (artigo 28, § 2º, da

Lei nº 11.343/2006), inclusive o correu João já julgado o delatou na instrução que o condenou (fls. 261/266). Por fim, não é o caso de desclassificação para o artigo 37 da Lei nº 11.343/2006, porque o réu contribui ativamente para a realização do tráfico de drogas, não se trata de um mero colaborador. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Jose Eduardo Vecha, pela prática

do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (42 porções de cocaína, pesando 16,7g, 42 porções de cocaína pesando 6,7g e 16 porções de maconha, pesando 19g - fls. 14/15, 18/21 e 106/109) não permitem aumentar a pena, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 57/58 e 325/326). Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes ou atenuantes a serem apreciadas. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento a serem apreciadas, contudo reduzo a pena em 2/3, passando para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa. Ressalto que entendo que poderia me utilizar da natureza e da quantidade das drogas, para fins de obstar o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Contudo o Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 712, seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.887.511/SP, passaram a entender que não é possível a utilização da natureza e da quantidade das drogas na terceira fase de aplicação da pena. Outrossim, não há outro critério para a redução da pena entre 1/6 e 2/3, a não ser a natureza e a quantidade das drogas, mas, como já dito, ela não pode ser utilizada na terceira fase da dosimetria da pena, por esta razão reduzi a pena no máximo de 2/3, pois, não havendo outro critério a ser utilizado, e não há, o juiz não poderia quantificar a pena a seu bel-prazer, pois agindo assim estaria violando o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Inclusive, nos processos nos 1500527-09.2020.8.26.054 (fls. 318/325) e 1501072-79.2020.8.26.0540 (fls. 426/435), que tramitam nesta Vara, foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça que este magistrado recalculasse a pena com base nestes parâmetros. Desta maneira, por segurança das relações jurídicas, passo a dosar a pena, conforme a mencionada orientação dos Tribunais Superiores. No caso do tráfico de drogas, o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 determina que o juiz "na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente" - (grifei). Ou seja, a fixação da pena compreende a dosimetria e o regime inicial de cumprimento, tanto que o legislador ressaltou que a natureza e a quantidade das drogas e a conduta social preponderam sobre o artigo 59 do Código de Processo Penal, e este artigo (59 do Código de Processo Penal) deve ser considerado na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, conforme prevê o artigo 33, § 3º, do Código de Processo Penal. Desta maneira, fixo o regime inicial de cumprimento da pena semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, a despeito de a pena ser inferior a quatro anos e o réu não ser reincidente (fls. 57/58 e 325/326), a natureza e quantidade das drogas apreendidas (42 porções de cocaína, pesando 16,7g, 42 porções de cocaína pesando 6,7g e 16 porções de maconha, pesando 19g - fls. 14/15, 18/21 e 106/109), preponderam sobre o artigo 59 do Código Penal, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, e o artigo 59 do Código Penal deve ser levado em consideração na dosimetria da pena, segundo preceitua o artigo 33, § 3º, do Código Penal. Neste sentido a jurisprudência: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENA E RECUSA DE ENVIO À PGJ. RECUSA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELO PARQUET. ANUÊNCIA DO MAGISTRADO. PROPOSTA DE REVISÃO REQUERIDA A DESTEMPO PELA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 20/2/2020; HC 180.365-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 27/3/2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FÉLIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe de 3/4/2018. 2. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal para certos tipos de crimes, principalmente no momento presente, em que se faz necessária a otimização dos recursos públicos. Com efeito, o membro do Ministério Público, ao se deparar com os autos de um inquérito policial, a par de verificar a existência de indícios de autoria e materialidade, deverá ainda analisar o preenchimento dos requisitos autorizadores da celebração do ANPP, os quais estão expressamente previstos no Código de Processo Penal: 1) confissão formal e circunstancial; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e 3) que a medida seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto. 4. Conforme o acórdão ora impugnado, o requerimento de revisão do não oferecimento de proposta do ANPP, para fins de análise do órgão superior do Ministério Público local, ocorreu a destempo pela defesa, deixando que a instrução criminal fluísse regularmente. 5. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a quantidade e a qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. 6. No caso, embora estabelecida a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão, a quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos (16 porções de maconha, pesando 66,2 gramas; 44 porções de cocaína, pesando 39,6g; 33 porções de crack, pesando 7,1g; - 13/16 e 70/71) , utilizadas na escolha do patamar de diminuição do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, o semiaberto, em razão da quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos. 7. Habeas corpus não conhecido.” - (grifei). (HC 612.449/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020). “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAFASTÁVEL A INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. IMPOSIÇÃO JUSTIFICADA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte a quo afastou a aplicou a minorante considerando as circunstâncias fáticas da causa, qual seja, a quantidade e variedade das drogas apreendidas. Entender de forma diversa exigiria, necessariamente, incursão na matéria fático-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. A quantidade e natureza das drogas apreendidas - 116 porções de maconha- constituem fundamentos idôneos para o agravamento do aspecto qualitativo da pena, ou seja, para a fixação de regime mais gravoso, no caso o semiaberto. 3. Tendo a reprimenda ultrapassado os 4 anos de prisão, a circunstância judicial desfavorável (quantidade da droga) justifica a fixação do regime inicial semiaberto, segundo a jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.” - (grifei). (AgRg no AREsp 1671723/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO.

PRECEDENTES. NEGATIVA

DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 27/7/2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. III - Ademais, a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta requer fundamentação específica, baseada em elementos concretos extraídos dos autos. Inteligência das Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719 do STF. IV - No caso, aplicada a pena de 2 anos de reclusão, entendo que deve ser estabelecido o regime inicial intermediário, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, e do art. 42 da Lei de Drogas. A quantidade e variedade dos entorpecentes podem ser utilizadas como fundamento a ensejar a aplicação do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06. V - O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o HC n. 97.256/RS, reconhecendo a inconstitucionalidade da parte final do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, passou a admitir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. VI - Na hipótese em análise, a quantidade e diversidade das drogas apreendidas (16 porções de maconha, pesando 66,2 gramas; 44 porções de cocaína, pesando 39,6g; 33 porções de crack, pesando 7,1g; - 13/16 e 70/71) não recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, consoante o disposto no art. 44, inciso III, do Código Penal, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na negativa da benesse em tela. Habeas corpus não conhecido. Ordem de ofício apenas para fixar o regime semiaberto para resgate da reprimenda, mantido os demais termos da condenação." - (grifei). (HC 581.356/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020). "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO ADEQUADO. AFASTAR CARÁTER HEDIONDO. PLEITO PREJUDICADO. DETRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Concluído pelas instâncias antecedentes, com fulcro nos elementos constantes dos autos e no fato de registrar atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, que o agravante se dedica ao tráfico de drogas, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes. 4. Embora o agente seja primário e a pena reclusiva tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento das sanções impostas, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade e natureza de entorpecente), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 5. Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos de reclusão, é inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a ausência de preenchimento de requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal). 6. Fica

prejudicado o pleito de afastamento do caráter hediondo do delito, pelo não reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado. 7. Noticiado o trânsito em julgado da ação penal, caberá ao Juízo de execução penal averiguar a possibilidade de estabelecimento de regime mais brando diante do desconto do período em que o agravante permaneceu preso preventivamente. 8. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 573.149/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020) - (grifei). Não substituo a pena do réu, porque, nos termos do artigo 44, § 3º, do Código Penal, não é socialmente recomendável, pela natureza e quantidade das drogas (42 porções de cocaína, pesando 16,7g, 42 porções de cocaína pesando 6,7g e 16 porções de maconha, pesando 19g - fls. 14/15, 18/21 e 106/109), fato concreto que impede a substituição. Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 26). Com relação aos objetos apreendidos, dinheiro e drogas já foi decidido sobre a destinação e destruição deles no processo desmembrado (fls. 265/266). III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO o réu JOSÉ EDUARDO VECHA (R.G. nº 25.267.151 - filho de José Aparecido Vecha e Zezineia Damião da Silva Vecha - fls. 23 e 32), pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, a 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 166 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual solto (fls. 76/78). O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Oficie-se imediatamente ao estabelecimento penal, no qual o réu está preso provisoriamente para transferi-lo ao regime adequado, nos termos do Súmula vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; b) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; c) realizadas as providências anteriores, archive-se o processo. Autorizo a extração de cópias. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."Pelo Dr. Defensor Público e pelo réu foi dito que manifestam o desejo de recorrer da Sentença proferida, requerendo a defesa vistas após expedição da guia provisória. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso requerido pela Defensoria Pública e pelo réu. Dê-se vistas dos autos à Defensoria para apresentação das razões após expedição da guia provisória. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.